

1500339-39.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... e até mesmo hierarquia entre os envolvidos no tráfico de entorpecentes.

Não há investigação sobre fatos anteriores à data do ocorrido ou mesmo qualquer prova obtida no transcorrer da instrução a demonstrar que os réus tivessem prévia associação voltada ao narcotráfico.

Desse modo, não se admite a condenação pelo crime de associação para o tráfico quando a prova dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1500339-39.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500339-39.2021.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mateus Batista da Costa e outros

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Mateus Batista da Costa, José Victor Ferro de Souza e Lucas Antony Ribeiro da Silva foram denunciados pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06, porque se associaram para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas em data anterior a 9 de março de 2021. Consta, também, que no dia 9 de março de 2021, na rua Salim Rechoan, n. 166, Água Quente, Taubaté, previamente ajustados e com unidade de desígnios, os réus possuíam e mantinham em depósito drogas para fins de tráfico.

Segundo a denúncia, os réus se associaram para praticar o tráfico de drogas e adquiriram grande quantidade de entorpecentes, que eram armazenadas e preparadas no apartamento de Mateus, localizado no endereço acima descrito.

Na data dos fatos, os réus mantinham em depósito no imóvel uma bolsa térmica verde

contendo 197 porções prontas para venda de maconha, uma porção maior de maconha e diversas sacolas plásticas usualmente utilizadas para embalar drogas.

Ocorre que os réus foram surpreendidos por policiais militares, que cumpriam mandado de prisão contra outra pessoa. Após ser franqueado o acesso da equipe policial por Mateus, os agentes públicos visualizaram José Victor e Lucas Antony no quintal da residência, tendo este arremessado para o imóvel vizinho uma bolsa térmica e um telefone celular, conduta que foi flagrada pelos policiais.

Submetidos à revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os réus. Entretanto, após efetuarem buscas na residência vizinha, os policiais encontraram os objetos dispensados por Lucas Antony, descobrindo as drogas que mantinham em depósito. Somado a isso, foi localizado e apreendido um telefone celular próximo aos pés de José Victor.

A denúncia foi recebida às fls. 108/110.

Citados (fls. 120, 129 e 130), os réus apresentaram resposta escrita à acusação (fls. 128, 131 e 138/143).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e os réus foram interrogados. Ao cabo da fase instrutória, determinou-se a juntada dos laudos periciais faltantes e a acusação e a respectiva defesa apresentaram memoriais finais.

O Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal. Argumentou que não há provas do vínculo associativo entre os réus, mas todos devem ser condenados pela prática de tráfico de drogas. No que tange ao crime de tráfico, enfatizou a prova colhida durante a instrução e a fase do inquérito. Pontuou que Mateus permitiu o acesso dos milicianos ao imóvel. Afirmou que Lucas e José se aproveitaram de Mateus e de sua residência para praticar crime. Disse que a quantidade de drogas exige exasperação da reprimenda. Aduziu que somente Mateus pode ser beneficiado com o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Aduziu que Lucas possuía menos de 21 anos de idade na data dos fatos. Requereu a imposição de regime fechado a José e Lucas.

Mateus Batista da Costa pugnou pela sua absolvição por falta de provas da associação e do tráfico. Argumentou que os documentos juntados demonstram que o réu é acometido por doença descrita como atraso mental. Na hipótese de condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, pleiteou a imposição de pena no mínimo legal, pois favoráveis as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42, da Lei de Drogas.

José Victor Ferro de Souza requereu a absolvição ante a ausência de provas que leve a crer que o réu tenha se relacionado de forma estável e permanente com os demais indivíduos para a prática do tráfico. Os depoimentos dos policiais colhidos em juízo foram imprecisos e incapazes de sustentar uma condenação. Pugnou pela absolvição do réu dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n.11.343/06. Caso não seja esse o entendimento, requereu a aplicação da pena base no mínimo legal e a fixação de regime aberto para o início do cumprimento de pena (fls. 410/413).

Lucas Antony Ribeiro argumentou que Matheus, que teria autorizado o acesso dos policiais ao imóvel, é acometido por doença mental, o que invalida as provas obtidas. Pleiteou sua absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Defendeu a fixação da pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, rogou pelo reconhecimento da atenuante relativa à menoridade relativa. Pediu a diminuição máxima da pena, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Requereu a fixação de regime aberto para início de cumprimento da pena, que permite substituição por restritivas de direitos.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada por meio da qual o Ministério Público atribuiu aos réus a autoria de tráfico de drogas e associação para o tráfico, dando-os como incurso nas penas previstas nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06.

Preliminarmente, a Defesa de Lucas Antony Ribeiro da Silva busca a nulidade das provas obtida pela polícia por invasão de domicílio. Argumenta que a pessoa que autorizou o acesso dos policiais é portadora de atraso mental, o que retira a licitude da diligência.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe ao ordenamento jurídico nova visão sobre as pessoas com deficiência. A Lei n. 13.146/15 estampa em seu artigo 1º o principal objetivo da norma: assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania.

Partindo desse norte, houve expressa alteração do antigo conceito de pessoa incapaz para todo o ordenamento jurídico, mas principalmente no âmbito do Direito Civil. Vale dizer, aqueles que antes eram considerados absolutamente incapazes tão somente em razão de sua deficiência foram alçados ao status de plena capacidade civil ou, no máximo, de incapacidade relativa relacionada a determinados atos ou a forma de exercê-los.

Não se olvida que o critério biopsicológico foi adotado pelo direito brasileiro, especialmente pelo sistema penal, nos termos do artigo 26, do Código Penal. Todavia, o “atraso mental” de Mateus, conforme por ele próprio explicado em juízo, somente constitui percalço em seu desenvolvimento escolar, razão pela qual é beneficiário do LOAS.

Ao contrário do que tenta convencer a ilustre defesa de Lucas, o corréu Mateus demonstrou, durante todo o curso do processo, que possui desenvolvimento mental completo e, ao tempo dos fatos, era inteiramente capaz de distinguir lícito de ilícito e se determinar conforme seu próprio entendimento. Interrogado em juízo, relatou os fatos de forma clara, concatenada, lógica e lúcida.

Nessa esteira, não há que se falar em qualquer irregularidade na conduta dos policiais, que foram autorizados pelo proprietário do imóvel a acessar o local.

Não se pode olvidar que “o incidente de insanidade mental é prova pericial constituída em favor da defesa” (STF, HC 133.078/RJ, 2ª Turma, Min. Cármen Lúcia, 6.9.2016), diligência que não foi postulada pelo réu justamente por não haver dúvida sobre a sua imputabilidade.

No mérito, a materialidade e a autoria delitivas estão escoradas em boletim de ocorrência (fls. 3/6), termos de depoimentos (fls. 16/18), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudos periciais (fls. 9/13, 326/334), termo de interrogatório (fls. 19/21), laudo toxicológico definitivo (fls. 212/214) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Frank Jackson dos Santos disse que foi à residência para buscar uma pessoa que era procurada. Pelo vão do portão, visualizou duas pessoas no quintal. Chamou o morador e Mateus atendeu a equipe policial. Indagado sobre as pessoas, Mateus disse que

estava sozinho e abriu o portão. Nesse momento, viu Lucas arremessando uma bolsa verde por cima do muro, em direção à casa vizinha. Entraram no imóvel com autorização de Mateus, onde os outros réus foram abordados. Questionados, disseram que não tinham nada, mas o imóvel vizinho foi revistado e a bolsa verde contendo drogas foi encontrada. Informou que havia um mandado de busca envolvendo outra pessoa, posteriormente identificada como irmão de Mateus. Disse que o procurado não morava no local. Tratava-se de uma casa. Contou que havia aproximadamente duzentas "buchas" de maconha. Inicialmente, os réus disseram que não haviam dispensado nada. Posteriormente, confessaram que o local era utilizado para fracionamento da droga para venda posterior. Mateus disse, ainda, que recebia dinheiro para que os demais corréus dividissem as drogas no local. Afirmou que a residência dos demais acusados não foi alvo de buscas. Não conhecia os réus. Pelo que se recorda, o telefone celular de Lucas foi apreendido, pois também fora dispensado por cima do muro da casa. Enfatizou que as drogas estavam em uma bolsa verde, mas não soube precisar outros detalhes do objeto. (Identificou Lucas como a pessoa sentada no canto esquerdo da imagem). Informou que o telefone de Lucas foi encontrado no imóvel ao lado e o corréu confirmou a propriedade do objeto. Disse que somente foi à casa ao lado para pegar a bolsa. Asseverou que não efetuou diligências na casa de Victor, pois já havia elementos para a prisão em flagrante. Disse que Mateus saiu de dentro da casa e abriu o portão aos policiais. Afirmou que a esposa de Mateus também estava no imóvel, mas somente foi mantido contato com ela posteriormente, pois estava dormindo. Não soube qualquer informação sobre problemas de saúde de Mateus. Reiterou que Mateus confessou que, em troca de dinheiro, cedia seu quintal para que os corréus fracionassem drogas no local.

A testemunha Oesley Eduardo da Silva Pereira narrou que a polícia tinha conhecimento sobre a presença de uma pessoa contra a qual havia mandado de prisão. Ao chegar no local, percebeu que havia pessoas no quintal. Relatou que chamou pelo morador e Mateus atendeu aos policiais, mas disse que não havia mais ninguém no local. Viu o momento em que o corréu Lucas arremessou uma bolsa por cima do muro. Em buscas ao imóvel vizinho, foram localizados um telefone celular e uma bolsa verde contendo drogas. Indagados, os réus confessaram que o local era utilizado para fracionar drogas. Aduziu que Mateus recebia dinheiro para que os demais réus usavam sua casa para picar drogas. Acredita que o irmão de Mateus era o alvo do mandado de busca. Disse que não conhecia os acusados. Informou que não foi o responsável por buscar a bolsa, mas encontrou o telefone celular de Lucas fora da casa. Relatou que a bolsa verde foi jogada no quintal da casa de Lucas, informação que somente veio à tona posteriormente. Pelo que se recorda, havia diversas porções de maconha e uma porção maior. Segundo informado pelos acusados, Lucas e José utilizavam o quintal de Mateus para fracionar drogas. Mateus disse que somente cedia o espaço, mas não se envolvia com demais atos do tráfico. Asseverou que Lucas confessou que mantinha mais drogas em sua casa, mas nada foi encontrado no local por ele indicado. Afirmou que a polícia não foi à residência de José. Asseverou que a polícia tinha informações sobre a presença no imóvel de pessoa procurada. Disse que a equipe utilizava motos. Afirmou que seu colega de farda vislumbrou a bolsa verde ser jogada por cima do muro, motivo pelo qual pediram acesso à casa. Disse que não viu com clareza os objetos serem jogados por cima do muro. Comentou que Lucas indicou com precisão determinado local onde haveria drogas em sua casa, mas não havia nada de irregular. Aduziu que o bairro é conhecido pelo tráfico de drogas. Não se recorda se foi Lucas ou José Victor quem confessou a mercancia das drogas. Aduziu que o telefone celular foi encontrado em uma área verde, ao passo que a bolsa verde estava na casa de Lucas. Não viu de onde Mateus saiu para atender ao portão. Lembrou que, além dos réus, a esposa de Mateus também estava no local. Asseverou que Mateus informou que sua esposa tinha problemas de saúde, razão por que ela somente foi contatada com mais calma posteriormente. Não se lembra se a mulher falou que Mateus tinha alguns problemas de saúde.

Jaqueline Ribeiro Tavares disse que é vizinha do corréu Lucas e o conhece há aproximadamente quinze anos. Disse que nunca viu o acusado envolvido com o tráfico

de drogas. Afirmou que somente viu o corréu fumando maconha alguns dias antes, o que causou espanto, pois nunca havia visto conduta parecida. Informou que a rua em que mora é conhecida pelo movimento do tráfico, mas nunca viu envolvimento de Lucas. Asseverou que todos moravam na mesma rua, motivo pelo qual era comum vê-los juntos, inclusive José Victor fumando. Disse que mora na mesma região que todos os corréus e conhece a genitora de Mateus apenas de vista. Aduziu que se lembra de Mateus trabalhando, mas não sabe onde cada um dos réus estudou.

Jonatan Michel de Brito disse que José Victor trabalha como auxiliar de mecânico de instalação de aparelhos condicionantes de ar. Asseverou que nem sempre o corréu é chamado para trabalhar, mas costuma receber aproximadamente um salário mínimo. Informou que José Victor é colaborador assíduo e trabalha, quando chamado, entre as 8h e 18h. Não sabe qualquer informação negativa sobre o funcionário. Disse que, sempre que precisou faltar, apresentou justificativa.

José Victor Ferro de Souza, interrogado em juízo, negou a autoria dos fatos. Disse que é usuário de maconha e, enquanto caminhava pela rua, foi convidado por Lucas e Mateus para consumidor drogas. Disse que apenas conhecia os corréus de vista. Apenas aceitou o convite para usar drogas na casa de Mateus, mas sequer sabe de quem eram as drogas. Informou que estava fumando um cigarro de maconha. Aduziu que só havia os três no imóvel. Disse que Mateus o convidou para consumir droga. Contou que estava passando pelo local, pois mora na região. Não soube fornecer detalhes sobre a localização das drogas ou dos petrechos. Negou ter auxiliado Mateus no preparo das drogas. Disse que todos estavam juntos consumindo drogas no quintal da residência quando foram abordados.

Lucas Antony Ribeiro, interrogado em juízo, optou por permanecer em silêncio.

Interrogado, Mateus Batista da Costa negou a autoria dos fatos. Disse que os policiais bateram em seu portão e falaram que estavam procurando seu irmão. Disse que não viu qualquer mandado. Informou que estava com Vitão e Lucas na casa. Aduziu que os policiais “apareceram” com uma bolsa, que não estava no local. Contou que havia chamado os corréus para conversar na sua casa. Disse que ninguém estava usando drogas em sua casa na data dos fatos. Admitiu que é usuário de cocaína. Asseverou que apenas permitiu que os corréus entrassem em sua casa para usar o banheiro, mas não era comum que eles entrassem no local. Afirmou que as drogas não foram localizadas no interior de sua casa. Disse que Luís Gabriel dos Santos é seu irmão. Não conhecia os policiais responsáveis pela abordagem. Desconhece a versão dos policiais sobre a participação dos corréus no processo de fragmentação da droga. Afirmou que Victor e Lucas estavam nos fundos do imóvel quando a polícia entrou no local. Disse que possui atraso no desenvolvimento escolar. Narrou que o policial apontou a arma e mandou que encostasse na parede. Aduziu que é possível enxergar o quintal da casa pelo vão do portão.

A prova dos autos é insuficiente para provar a prévia associação entre os agentes para fins de tráfico de drogas. Isso porque não é possível afirmar, com absoluta certeza, que entre os réus havia o liame subjetivo e perene destinado ao ilícito comércio de drogas. Vale dizer, não há prova de que havia estabilidade, divisão de tarefas e até mesmo hierarquia entre os envolvidos no tráfico de entorpecentes.

Não há investigação sobre fatos anteriores à data do ocorrido ou mesmo qualquer prova obtida no transcorrer da instrução a demonstrar que os réus tivessem prévia associação voltada ao narcotráfico.

Desse modo, não se admite a condenação pelo crime de associação para o tráfico quando a prova dos autos apenas permite constatar mero vínculo ocasional. É exigido o animus associandi anterior entre os indivíduos, que devem agir de modo coeso, conjugando esforços, unindo suas condutas e dividindo tarefas para a prática de atividades criminosas, com a finalidade de praticar o ilícito comércio de

substância entorpecente.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa (HC 270.837/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015)." (HC 402527 / SP HABEAS CORPUS 2017/0133582-9. Ministro Ribeiro Dantas. DJe 19/12/2018).

Nesse passo, ausentes robustas provas para a configuração da associação para o tráfico, impõe-se a absolvição dos réus em relação ao artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

Por outro lado, resultaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33, da Lei de Drogas, que assim dispõe:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa "

Verifico que a conduta dos réus se enquadra em diversos verbos-núcleo do tipo, notadamente possuir drogas e mantê-las em depósito, em contrariedade à lei, resultando configurada a tipificação do crime.

A própria prisão em flagrante dos réus e a farta quantidade de entorpecentes localizados em uma bolsa, que foi arremessada por um dos acusados por cima do muro em direção ao imóvel vizinho, demonstram que os réus estavam envolvidos com o tráfico de drogas, pois os entorpecentes seriam destinados ao comércio e fornecimento a terceiros consumidores.

Somado a isso, a segura narrativa fornecida pelos policiais responsáveis pela abordagem e prisão dos acusados se mostrou absolutamente mais concreta e segura que as controversas narrativas fornecidas pelos réus.

Registro que os depoimentos prestados pelos policiais são coesos e harmônicos, inclusive reproduzindo, com fidelidade, o quanto afirmado no depoimento prestado na Delegacia de Polícia, dando conta do ocorrido na data dos fatos.

A propósito da questão, pacífico nos tribunais, inclusive nos superiores, que "O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos." (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013).

Ressalto que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância.

Em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

Não há razão para duvidar da palavra dos policiais que prestam serviço público de enorme utilidade à sociedade, mormente porque seus depoimentos encontram escoro nas

demaís provas idôneas produzidas nos autos.

O Estado credencia os policiais para o exercício da repressão criminal outorgando-lhes certa parcela do poder estatal e o Judiciário empresta essa mesma credibilidade quando chamados a prestar contas do exercício de sua função.

Por outro lado, as controvertidas e inidôneas versões formuladas pelos réus são absolutamente insuficientes para afastar sua respectiva responsabilidade pelo tráfico de entorpecentes. Conforme informado em juízo, José apenas teria sido convidado pelos outros dois acusados para fumar maconha no local, pois apenas os conhecia de vista. Contou que todos estavam no quintal do imóvel consumindo drogas quando foram abordados. Mateus, por sua vez, aduziu que atendeu os policiais na porta de casa, pois estavam procurando seu irmão. Asseverou que era possível visualizar o quintal da casa de onde os policiais estavam. Contou que ninguém estava consumindo drogas em sua casa.

Imprescindível pontuar que as drogas foram localizadas no imóvel vizinho, pois, assim que perceberam a presença da polícia no local, Lucas e José arremessaram uma bolsa que continha as porções de drogas pelo muro, em uma vã tentativa de se esquivar da polícia.

Em outro ponto, impõe-se a lembrança de que a quantidade de porções individualmente embaladas dos entorpecentes e o modo em que foram encontrados dão conta da traficância exercida. Juntos, os acusados armazenavam uma grande porção e outras 197 pequenas porções individuais, todas de maconha, totalizando 345,42 gramas da droga (fls. 9/13 e 212/214).

Como assentado no Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, e a forma como elas estavam embaladas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes" (Apelação nº 3004054-64.2013.8.26.0272, Rel. Luis Augusto de Sampaio Arruda, j. 20.7.2017).

Quem é apanhado, como aqui, mantendo em depósito e na posse de grande quantidade de drogas, já embalada para entrega e consumo imediato, não tem como justificar outra situação senão aquela que aos olhos salta: traficância.

Impõe-se, agora, apreciar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Verifico, pelo que infere das provas colhidas, que todos os três réus são primários e têm bons antecedentes (fls. 58/65). Não fez prova o Ministério Público de que os réus se dediquem ao crime ou façam parte de associação criminosa. Ao que consta dos autos, os acusados apenas traziam consigo e armazenavam aquelas porções de droga com eles localizadas e apreendidas, conduta isolada e que possibilita prover-lhes nova chance para que se ajustem ao meio social em que vivem.

Destarte, fazem jus à redução em patamar máximo.

Analisadas as teses da acusação e das respectivas defesas, conclui-se que os réus eram, na data dos fatos, imputáveis. Tinham plena consciência da ilicitude de seus atos, não vindo em socorro quaisquer causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

A prova é certa, segura e da conta do cometimento das condutas imputadas aos réus, que devem responder penalmente por seus atos.

Estabelecida a responsabilidade criminal dos réus, passo à dosimetria da pena, com

fundamento no artigo 68, do Código Penal, atento ao critério trifásico desenvolvido por Nélson Hungria e obediente ao princípio da individualização da pena.

Na primeira fase da dosimetria, impende observar a regra do artigo 42, da Lei 11.343/2006, pelo qual preponderam sobre o artigo 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social dos agentes.

A natureza e a quantidade das drogas pesam em desfavor dos réus, pois se trata de expressiva quantidade de maconha (345,42 gramas), droga já individualizada e embalada em quase duzentas porções, estocadas em casa, prontas para serem entregues aos usuários consumidores, o que justifica o aumento da pena-base.

Não há elementos para valorar a personalidade do corréu Lucas.

A personalidade de Mateus e José Victor – que no entender de Guilherme Nucci é aquela que está vinculada às qualidades morais, às distorções de caráter, à índole do sujeito, que são extraídos de sua forma habitual de ser, agir e reagir (in Individualização da pena, RT, 2005, p. 207) – se mostra negativa.

Isso porque resultou claro que ambos os réus mentiram em Juízo, trazendo falsas exposições acerca de como se passaram os fatos, visando a uma injusta absolvição. Essa atitude demonstra a distorção de caráter e a ausência de senso moral por parte do réu, que se vale da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e, maliciosamente, induzir em erro o julgador, com afronta à dignidade da justiça.

Sobre a questão, oportuno ressaltar que ainda que seja o interrogatório um meio de defesa e de prova, evidente que o réu deva respeitar as limitações impostas pelas regras do processo, especialmente aquelas decorrentes da lealdade, da ética, da boa-fé, não se podendo esquecer que o processo é um instrumento para a realização da Justiça, dotado de uma série de formalidades que, em ultima ratio, são verdadeiras garantias para o réu, como também para a sociedade.

Ora, é forçoso reconhecer que o réu ao mentir deliberadamente extrapola os limites da autodefesa – que não é absoluta – demonstrando torpeza e deslealdade processual, expondo a risco a Justiça que pode, em razão de seu proceder, proferir decisão equivocada e, assim, injusta.

Afigura-se evidente que não se pode tolerar que o réu se valha de engodos, ardis e mentiras visando a escapar de uma justa condenação. O acusado que assim age, frauda a produção de provas e torna o processo uma chicana pessoal e egoísta, revelando sua personalidade dissimulada, amoral, o que justifica a elevação da pena.

Acerca do tema, pertinente o registro da lição de Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): “Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar – até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente”.

O entendimento acima explicitado, ainda que minoritário na jurisprudência, tem sido prestigiado em várias decisões judiciais, cabendo o registro, por todas, de parte do judicioso voto da lavra do Desembargador José Raul Gavião de Almeida, na Apelação 00771651-20.2015, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 30 de novembro de 2017:

“...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque

elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade"

Ainda sobre o tema, se revela oportuno registrar parte do artigo "A mentira do réu como elemento relevante na dosagem da pena", da lavra do Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Cleber Pereira Defina, que de forma judiciosa analisou o tema:

"...assim como a confissão dos fatos denota aspecto louvável da personalidade do agente, pois atua com boa-fé e consciência social, o inverso também é verdadeiro: a mentira do agente sinaliza aspecto censurável de sua personalidade, pois atua com má-fé e franca ausência de consciência social, constituindo-se, portanto, em dado sensível quando da individualização da pena. O indivíduo que mente à autoridade só pretende beneficiar-se com a própria torpeza, conduz ao indesejável erro judiciário, prejudica o direito das vítimas e mina a justiça. Este cenário ratifica a deformação dos valores carregados pelo acusado pinoquista, repercutindo em necessidade ainda maior de reconstituição da tábua de valores socialmente almejada em relação ao acusado enganador. Ora, se é justo que a postura de lealdade do imputado deve surtir efeito no sentido de diminuir sua reprimenda, porque atrelada a condições favoráveis de sua personalidade, segue-se clarivamente que há mesma justiça em extrair efeito no sentido de agravar a reprimenda do réu que ostenta péssima personalidade caracterizada pela insolência de mentir perante as autoridades que colheram sua versão dos fatos, especialmente quando a este acusado lhe foi garantido o direito ao silêncio. Aliás, onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira. O mesmo Estado que garante ao processado o direito ao silêncio, a possibilidade de não se autoincriminar, que pode criar recompensas para este falar, como é o caso da atenuante da confissão e do acordo da delação premiada, também deve poder intensificar a reprimenda daquele que ousa falar com o exclusivo propósito de enganar e promover injustiça. O embuste, tanto quanto a lealdade, é vetor a moldar a pena justa, pois ambos dizem respeito à personalidade refletida do agente"http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/148/68).

Em suma, todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (*nemo tenetur se detegere* ou *privilege against self incrimination*); contudo, tal direito não pode admitir a interpretação que alguns lhe emprestam de tornar aceitável, ou pior, irrelevante, a conduta comissiva de mentir, que é vil, antiética e contrária aos valores mais mezinhas da sociedade, ao revés, deve o julgador, por ocasião da individualização da pena, caso constatado que o réu mentiu ao ser interrogado em juízo, fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, amparado na personalidade negativa do acusado, pois evidente a ausência de senso moral, denotando índole desviada e personalidade distorcida, daquele que podendo se calar opta deliberadamente por mentir em juízo.

Não se pode olvidar, ainda, que o réu, desde a promulgação da Lei 11.719/2008, é interrogado após a colheita de todas as provas, inclusive depoimento das testemunhas, de forma que tem plena consciência das provas produzidas e da sua repercussão, mormente em razão da defesa técnica que o assiste, razão pela qual a sua opção pela mentira se mostra ainda mais censurável, cínica e abjeta, pois abre mão do direito ao silêncio, e até mesmo da atenuante da pena da confissão, para tentar induzir em erro o juízo e assim ferir a dignidade da justiça.

A propósito, impende registrar, por relevante, que caso o julgador não aumente a pena do acusado mendaz, "estará incentivando o réu a sempre mentir, afinal, se sua

mentira não lhe causa qualquer prejuízo, podendo, inclusive, livrá-lo de uma condenação justa, por que confessar um crime ou mesmo ficar em silêncio? Não punir o acusado mentiroso, aliás, viola o princípio da individualização da pena, pois equipara equivocadamente a situação do réu que fica em silêncio em seu interrogatório, com a do que mente descaradamente, em verdadeira afronta à dignidade da Justiça, pois tem o único propósito de induzir esta em erro, minando, assim, sua credibilidade perante a sociedade" ("A mentira do réu e a Dosimetria da Pena", artigo de autoria do Promotor de Justiça André Wagner Melgaço Reis, disponível em).

Nesse passo, cabe trazer recentíssima decisão proferida pelo voto do i. Desembargador Tetsuzo Namba:

"...demais disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no momento que se pronunciavam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o patrocínio indevido da "não verdade", isso mostra o caráter de alguém, flagrado no cometimento de infração penal, não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações... (TJSP – Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625, 8.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28.11.2019).

Cabe anotar que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento recente, por votação unânime, decidiu no mesmo sentido da tese que ora se adota, trazendo excertos de decisão proferida por este juízo como razão de decidir, como se infere dos autos da Apelação 0000129-67.2018.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Roberto Porto:

"Ademais, como bem destacou o Ministério Público a fl. 277 o fato de o réu ter mentido em Juízo, trazendo aos autos fatos absolutamente inverídicos, revela sua personalidade desvirtuada, devendo ser considerado no momento da exasperação da reprimenda. Aliás o Douto Magistrado bem fundamentou a exasperação da pena-base..."

No mesmo sentido já decidiu a Colenda 14^a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime nos autos da apelação 0000640-36.2016.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Walter da Silva:

"(...) Em relação ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03: Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, fundamentando o douto Magistrado na personalidade negativa do apelante, pois demonstrou perante o Juiz desonestidade e insinceridade, o que revelou a distorção de caráter, e assim a reprimenda foi tornada definitiva na ausência de outras causas modificadoras."

Ainda sobre a mentira do réu como circunstância desfavorável, com enfoque na personalidade desviada, em voto proferido pela 6^a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pela voz do ilustre relator Zorzi Rocha, assentou:

"Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça" (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, j. 3.10.2019).

Não outra a conclusão a que chegou o ilustre Des. Ricardo Sale Júnior, chamando atenção para a correção do decisum que elevou a pena-base pelo fato de haver o réu mentido ao ser interrogado em juízo “fato que evidencia uma personalidade voltada para o crime” (TJSP, Apelação Criminal 0002205-19.2013.8.26.0625, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. em 8.8.2019).

No mesmo sentido o voto da lavra do ilustre Des. Tetsuo Namba, ao aduzir correta a sentença que reconheceu a mentira do réu como personalidade deturpada, justificando-se a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. (TJSP, Apelação Criminal 0001091-27.2017.8.26.0618, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. em 5.12.2019).

Também em processo que teve trâmite por esta 3ª Vara Criminal, em sede de apelação (Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625), a i. Desembargadora Ivana David, assentiu com a tese ora perfilada, nos termos seguintes, fazendo alusão, em parte, à decisão proferida nos autos do Processo Criminal nº 0003339-30.2014.8.26.0372 (1ª Vara Judicial de Hortolândia, Juiz de Direito Luís Mário Mori Domingues j. 21.01.2015):

“(...) escoreita a majoração praticada, uma vez que ao mentir em juízo, a acusada foi muito além do seu direito ao silêncio, mentindo para a Justiça, tentando se esquivar das consequências dos seus atos, porquanto, “nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo”, demonstrando, com isso, além da má índole, que o crime não constituiu um episódio acidental em sua vida” (TJSP, Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625; 4ª Câmara de Direito Criminal, Relatora Desembargadora Ivana David, j. em 10.12.2019)

A culpabilidade dos agentes é natural à espécie. Acerca da conduta social dos réus não se tem elementos para sua valoração. Os motivos do crime e as circunstâncias são naturais ao tráfico de drogas, bem como as consequências dele decorrentes, nada havendo a valorar. O sujeito passivo do tráfico de drogas é a coletividade, titular do bem jurídico a saúde pública, não havendo, então, falar-se em comportamento da vítima.

Assim, na fixação da pena-base, considerando a quantidade de drogas apreendidas e a personalidade dos agentes, elevo a pena de Lucas Antony em 1/6, ao passo que a de Mateus Batista e José Victor comporta aumento de 1/3, totalizando 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa e 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, respectivamente.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, verifico que a idade do corréu Lucas Antony impõe atenuação da reprimenda (fls. 48). Assim, a pena de Lucas retorna ao patamar mínimo de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em atenção ao entendimento firmado na Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça, ao passo que mantenho inalteradas as reprimendas de Mateus e José.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem aferidas. Impõe-se, por outro lado, o reconhecimento da causa de diminuição de pena consistente no tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, diminuindo a reprimenda de 2/3, alcançando o importe de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa (Lucas), e 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 222 dias-multa (Mateus e José Victor).

Quanto ao regime inicial, de se lembrar que o tráfico privilegiado não ostenta natureza hedionda (Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 118.533/MS). Sendo a condenação inferior a 4 anos, somada à natureza dos entorpecentes localizados na posse dos acusados, bem como às circunstâncias quase integralmente favoráveis, entende-se que, nesse caso, excepcionalmente, o regime imposto deve ser o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal.

Nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira dos réus, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Excepcionalmente, no caso concreto, mostra-se possível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Isso porque todas as penas são inferiores a 4 anos, o crime não foi cometido com violência e os réus não são reincidentes. Além disso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição será suficiente.

Considerando que todas as reprimendas são superiores a um ano, nos termos do artigo 44, § 2º, da Lei Penal, de rigor a substituição por duas penas restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade, que serão estipulados pelo juízo da execução, e limitação de finais de semana.

Em razão da substituição acima, incabível a suspensão condicional da pena, em razão do disposto no artigo 77, do Código Penal.

Concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade. Anoto que em razão da quantidade da pena imposta e das favoráveis circunstâncias judiciais, as penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos. Além disso, foi fixado o regime aberto para início do cumprimento das penas, que se mostra incompatível com a custódia cautelar.

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito dos acusados por conta do período que permaneceram presos cautelarmente, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas 'b' e 'c'. Nesse sentido: (STJ, HC 169.072/SP, Relator Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, julgado em 10.6.2010).

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, de acordo com ao artigo 804, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho parcialmente o pedido formulado na denúncia para o fim de:

a) absolver os réus Lucas Antony Ribeiro da Silva, Mateus Batista da Costa e José Victor Ferro de Souza de terem perpetrado o crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

b) condenar os réus (i) Lucas Antony Ribeiro da Silva à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa; (ii) Mateus Batista da Costa à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 222 dias-multa; e (iii) José Victor Ferro de Souza à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 222 dias-multa, todos como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Os réus iniciarão o cumprimento da pena em regime aberto, pena substituída por duas

penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana, concedido aos réus o direito de apelar em liberdade, condenado os réus ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei estadual 11.608/03.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar os réus para procederem ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal, assim como ao pagamento da taxa judiciária;
- b) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação dos réus;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 7 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA